

1500542-47.2022.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Natália Berti

Comarca: José Bonifácio

Foro: Foro de José Bonifácio

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 05/09/2022

... de um pote branco. A quantidade encontrada caracteriza o tráfico. O usuário indicou a casa, os residentes tinham passagem por tráfico. Denise, inclusive, era procurada por furto. Denise acompanhou a revista na residência. Daniel assumiu o tráfico e Denise afirmou que o auxiliava a fazer tráfico. Foi apreendida uma balança de precisão, com resquícios de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de José Bonifácio

Foro de José Bonifácio

2ª Vara

Av. Monsenhor, 1000, Jardim das Palmeiras - CEP 15200-000, Fone: (17)3245-3348,

José Bonifacio-SP - E-mail: josebonif2@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500542-47.2022.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2078176/2022 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 23762627 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 523/22/321 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENISE DE CAMPOS BICUDO e outro

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA e outro

Artigo da Denúncia:

*

1. Aos 02 de setembro de 2022, às 14:00 horas onde presente estava o(a) Meritíssimo(a) Juiz(a), Senhor(a) Doutor(a) NATÁLIA BERTI foi aberta audiência designada nos autos supramencionados. conforme os termos do Comunicado 284/2020, emitido pelo E. Tribunal de Justiça, considerando a pandemia vivenciada (COVID-19).
2. Feito o pregão, verificou-se o seguinte: PRESENTE o(a) DD Promotor(a) de Justiça e Representante do Ministério Público, Senhor(a) Doutor(a) CÉSAR BOCUHY BONILHA; PRESENTES oa(s) ré(u)(s) DENISE DE CAMPOS BICUDO e seu/sua Defensor(a) Dr(a). ISABELLA LEITE PAULINO e DANIEL DE SOUZA seu/sua Defensor(a) Dr(a). JAIME AIRES DIONYSIO; e a(s) testemunha(s) DAVID TORRES, PEDRO LUIZ ABREU DE CAMPOS, ERIVALDO PEREIRA DOS SANTOS, JOSUEL ARAUJO LIMA.
3. Iniciados os trabalhos, o(a)(s) réu/ré(s) declararam expressamente que conversaram com o(a) seu/sua Defensor(a) antes da realização desta audiência, garantindo-se ainda ao(s) réu/ré(s) e a seu/sua Defensor(a) todos os meios assecuratórios da ampla defesa e contraditório. Na oportunidade, a MM Juíza advertiu a todos acerca do Comunicado 284/2020, bem como prestou maiores informações sobre a realização de videoconferência e das circunstâncias acerca da pandemia vivenciada.

Após, o(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) ouviu a(s) Testemunha(s) de Acusação e Defesa DAVID TORRES, PEDRO LUIZ ABREU DE CAMPOS, ERIVALDO PEREIRA DOS SANTOS. Dada a palavra ao Dr. Promotor e aos Defensores, foi dito que: MMª. Juíza de Direito, desisto da oitiva da(s) testemunha(s) JOSUEL ARAUJO LIMA. Em seguida, pela MMª. Juíza de Direito foi dito que: Homologo a desistência apresentada.

Por fim, a Meritíssima Juíza realizou o Interrogatório do(a)(s) Ré(u)(s) DENISE DE CAMPOS BICUDO E DANIEL DE SOUZA

4. Então, a Meritíssima Juíza DECLAROU FINDA A INSTRUÇÃO e concedeu a palavra à Acusação e à Defesa, nesta ordem, para a apresentação dos memoriais e alegações finais orais. O(A) DD Promotor(a) de Justiça manifestou-se oralmente e o conteúdo de sua manifestação foi gravado por meio audiovisual. De forma sucinta, a Representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação. ALEGAÇÕES FINAIS DEFESA - Por seu turno, as Defesas também ofereceram alegações finais orais em audiência, cujo teor foi gravado para posterior reprodução. Em síntese, a defesa requereu a improcedência da ação.

5. Terminados os debates, a Meritíssima Juíza proferiu a seguinte SENTENÇA: Vistos.

DANIEL DE SOUZA e DENISE DE CAMPOS BICUDO, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas sanções do art. 33, caput, art. 34 e 35, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, no dia 21 de março de 2022, por volta das 23h20, na Rua Santos Dumont, nº 367, fundos, no bairro Jardim do Bosque, nesta cidade e comarca de José Bonifácio, DANIEL DE SOUZA e DENISE DE CAMPOS BICUDO, com dados de qualificação respectivamente às fls. 07 e 15, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o tráfico ilícito de drogas, e nesta qualidade guardavam e tinham em depósito para fins de tráfico, 1.276,52 grama(s) (um quilo, duzentos e setenta e seis gramas e quinhentos e dois miligramas) de THC - Tetrahydrocannabinol, divididos em 209 porções e 03 tijolos, e 10,22 grama(s) (dez gramas, duzentos e vinte miligramas) de cocaína na forma crack, divididos em 36 porções, ambas substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, o que faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Auto de Exibição e Apreensão da droga apreendida às fls. 118/119, Laudo de Constatação Preliminar de fls. 122/125, Laudo de Exame Pericial definitivo de substância entorpecente juntado às fls. 251/253).

Consta ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, DANIEL DE SOUZA e DENISE DE CAMPOS BICUDO, com dados de qualificação respectivamente às fls. 07 e 15, possuíam e guardavam, ainda que gratuitamente, instrumento/objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se, que os denunciados se associaram para o fim de praticarem o crime de tráfico ilícito de drogas na Cidade de José Bonifácio, utilizando-se da residência do casal, localizada na Rua Santos Dumont, nº 367, fundos, no bairro Jardim do Bosque, como ponto de venda de entorpecente.

Assim no dia dos fatos, durante patrulhamento pela Av. Antônio Gonçalves da Silva, na altura do numeral 1445, os policiais militares David Torres e Pedro Luiz Abreu de Campos avistaram Erivaldo Pereira dos Santos, o qual mudou de direção ao avistar a viatura, chamando a atenção dos policiais, que decidiram pela abordagem. Durante busca pessoal, encontraram um cachimbo, tipo marica, para fumar crack. Ao ser questionado, o acusado informou que comprou uma pedra de crack de um casal, pelo preço de dez reais, na Rua Santos Dumont, 367 - fundos, próximo do local da abordagem, e que já havia consumido a droga.

Na sequência, os policiais foram ao endereço informado e encontraram a denunciada DENISE DE CAMPOS BICUDO, que estava na porta da cozinha e autorizou a entrada deles na residência. Na sala, estavam o denunciado DANIEL DE SOUZA e o amigo Josuel Araújo de Lima. Em buscas pelo imóvel, os militares encontraram, numa sapateira, no quarto do casal, um potinho branco contendo em seu interior trinta e seis invólucros contendo crack, prontos para comercialização. Na penteadeira,

encontraram trezentos e oitenta e nove reais e uma folha de caderno contendo anotações da contabilidade do tráfico. Na cozinha, no motor da geladeira, encontraram duzentos e nove porções individuais de maconha, embaladas e prontas para venda, bem como três pedaços grandes de maconha. Na gaveta do armário na cozinha, encontraram uma balança de precisão com resquícios de cocaína e tetrahidrocanabinol (laudo pericial às fls. 254/257).

Durante a abordagem de Denize, encontraram em seu poder um telefone celular Samsung. Daniel, ao ser questionado, confirmou que a droga lhe pertencia.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos acusados e eles foram conduzidos para a Delegacia de Polícia. Lá, constatou-se que Denise era "procurada" pela Justiça. Indagados na Delegacia, o denunciado manifestou o desejo de permanecer calado e de falar somente em juízo. A denunciada negou os fatos.

As circunstâncias da prisão, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, aliadas à recente informação do usuário apontando a traficância perpetrada pelos denunciados, levam à conclusão de que todo o entorpecente apreendido era destinado ao tráfico ilícito.

Em vista disso, os denunciados foram presos em flagrante (Auto de Prisão em Flagrante de fl. 02/09).

A denúncia foi recebida em 20 de julho de 2022 (fls. 354/356).

Os acusados foram citados (fls. 292; 294), e foi apresentada resposta à acusação (fls. 335/344).

Foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que as testemunhas foram ouvidas, e os réus interrogados.

O Ministério Público requereu a procedência do pedido, nos termos da denúncia.

A Defesa requereu a improcedência da denúncia, com a absolvição dos réus.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A Defesa aduz, em matéria preliminar, a nulidade das provas, pois os réus não teriam franqueado a entrada dos policiais em sua residência, o que gerou a violação ao domicílio e à intimidade do acusado.

Entretanto, razão não lhe assiste. Sobre a alegada violação ao domicílio, importante destacar que o tráfico é delito de natureza permanente, pois sua consumação se prolonga no tempo. Por isso, aquele que o comete se encontra em situação de flagrância até cessar essa condição, nos termos do Código de Processo Penal, artigo 303, prescindindo-se de mandado judicial, a teor do que dispõe a CF/88, art. 5º, XI.

O texto constitucional trata da inviolabilidade domiciliar e de suas exceções no artigo 5º, XI ("a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial"). Há, portanto, quatro exceções à inviolabilidade: a) flagrante delito; b) desastre; c) prestação de socorro; e d) determinação judicial. Logo, caracterizada a situação de flagrante, é viável o ingresso forçado no domicílio.

Desse modo, no crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33), estando a droga em depósito na casa, o morador está em situação de flagrante delito, sendo passível de prisão em flagrante. Um policial, em razão disso, pode ingressar na residência, sem autorização judicial, e realizar a prisão. É o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e posse irregular de munição de uso permitido (artigo 12 da Lei nº 10.826/03).

Apreensão de razoável quantidade de entorpecentes (55 porções de cocaína com peso bruto de 82,0 gramas; e 60 porções de cocaína sob a forma de crack pesando 7,0 gramas), além de dinheiro – Irregularidade da invasão de domicílio. Crime permanente e estado de flagrância. Inocorrência – Pressupostos da segregação cautelar presentes – Réu reincidente específico e que ostenta maus antecedentes – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não

caracterizado - Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2270241-83.2020.8.26.0000; Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araras - Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 03/12/2020)

SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) - APELOS DEFENSIVOS BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E REDUÇÃO DAS PENAS. PRELIMINAR - NULIDADE - ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGADA ILICITUDE DA PROVA - INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL - INOCORRÊNCIA - TRÁFICO DE DROGAS - CRIME PERMANENTE - NULIDADE AFASTADA. MÉRITO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADAS - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE, UMA VEZ QUE INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, SUA FORMA DE ACONDICIONAMENTO E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO - CONDENAÇÕES MANTIDAS. PENAS - FIXADAS OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL - BASES ACIMA DO MÍNIMO EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES - REINCIDÊNCIA DO ACUSADO BEM RECONHECIDA - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO DO APELANTE POR QUE QUALIFICADA, SEM FALAR NO FLAGRANTE A ARREDAR A BENESSE - PRECEDENTE - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR, AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS - REGIME PRISIONAL FECHADO, PARA AMBOS, ADEQUADO À ESPÉCIE - DESCABIDA A APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO E INDEFERIDA A SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU "SURSI" - RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Criminal 1501780-09.2019.8.26.0559; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2020; Data de Registro: 27/11/2020)

Ressalte-se que esse juízo não desconhece o recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a ilicitude da prova colhida em busca realizada no interior de residência sem autorização judicial. No entanto, na situação em análise, o ingresso na residência ocorreu de forma legítima, diante das fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indicavam estar ocorrendo o armazenamento de substâncias ilícitas no interior da residência (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010).

Não bastasse isso, na delegacia e em juízo, os réus confirmaram que a ré Denise autorizou, expressamente, o ingresso dos agentes públicos na casa. Não há motivos para desmerecer a palavra dos policiais, já que eles nem sequer conheciam os réus, não havendo motivos para alteração da verdade dos fatos. Portanto, não há qualquer ilegalidade na conduta dos policiais militares, motivo pelo qual o pedido preliminar deve ser rejeitado.

Quanto ao pedido de instauração de incidente, tal requerimento também não deve prosperar. Não há quaisquer elementos a indicar que o acusado não possui capacidade de entendimento/autodeterminação. A simples alegação de que o acusado é usuário de drogas não é medida suficiente, por si só, para instauração do incidente. No mesmo sentido, o fato de ter usado drogas no dia dos fatos não afasta sua capacidade de entendimento.

Com efeito, a Defesa não apresentou qualquer documento ou outro elemento que indicasse eventual inimputabilidade ou semi-imputabilidade do acusado. É cediço que, para a instauração do incidente de sanidade mental, devem restar demonstrados indícios da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do agente, o que não aconteceu. No mais, o processo encontra-se formalmente em ordem, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Não havendo nulidades ou vícios a serem sanados. Os réus foram representados por Defensores e foram observados os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Não há questões preliminares a serem analisadas.

Assim, passo à análise do mérito.

A pretensão punitiva é PARCIALMENTE PROCEDENTE, pois as provas são suficientes para condenação apenas quanto ao delito do artigo 33, da Lei 11.434/06.

A materialidade deste delito evidencia-se pelo auto de prisão em flagrante delito

(fl. 01), termos de depoimentos (fls. 02/04), termos de declarações (fls. 05/06), interrogatório (fls. 07/08; 15/16), nota de culpa (fls. 09; 72), boletim de ocorrência (fls. 10/14), auto de exibição e apreensão (fls. 118/119), imagens (fl. 120), laudo pericial (fls. 122/125; 205/208; 229/236; 251/260; 305/312), relatório final (fls. 264/266), bem como pelas provas orais produzidas.

A autoria também é certa.

David Torres (testemunha comum) disse que estava em patrulhamento, viram um indivíduo e ele, ao vir a viatura, mudou de direção. Fizeram a abordagem e era Erivaldo. Ele tinha um cachimbo de crack, com resquícios. Indagado, Erivaldo disse que tinha adquirido o entorpecente em um local próximo, na Rua Santos Dumont, 367. Foram efetuar diligências e encontraram Denise na porta da cozinha, que permitiu a entrada. Na sala do imóvel, estava o esposo de Denise, chamado Daniel, o outro era Josuel, um amigo do casal. Denise acompanhou as buscas, autorizando. No quarto do casal, em um pote de pó royal, encontraram 35 invólucros de crack. Na sapateira, tinha uma quantia em dinheiro e folha de contabilidade de entorpecente. Na cozinha, no motor da geladeira, localizaram 200 porções de maconha, prontas para venda, além de 3 pedaços maiores de maconha (400g). Também foi encontrada uma balança de precisão. As três pessoas foram indagadas, Daniel e Denise assumiram a propriedade da droga e a venda. Josuel disse que não sabia sobre a droga. Havia, também, uma moto com numeração suprimida. Denise disse que comprara a moto em leilão, pagando R\$ 2000,00. Denise era procurada por furto qualificado. Não conhecia os réus, porém constou, em pesquisa, que Denise era procurado. Daniel também constava no sistema da polícia. O usuário disse que comprava drogas naquela residência há um tempo e que pegava o entorpecente, às vezes com uma mulher, às vezes com um homem. Não presenciaram ato de comercialização. Não tinham informações sobre aquela residência específica, mas o bairro é conhecido por ser local com pontos de vendas de drogas. A atitude do usuário foi suspeita, pois ele mudou de direção e passou a caminhar de forma mais rápida após ver a viatura. O usuário indicou aquela residência específica, indicando que pagou 10 reais pela porção de crack. Foram à residência por volta de 23h/23:30h da noite. Denise os recebeu e autorizou a entrada da equipe e acompanhou as buscas. A Polícia Civil não forneceu informações anteriores. A Polícia Militar, no momento, tinha fundadas razões sobre a venda de entorpecentes no local. A equipe que efetua a diligência pode comunicar ao superior sobre a ocorrência de flagrante, após a sua atuação. Na data, o depoente era a maior autoridade na rua naquela noite. Não existe procedimento que o obrigue a comunicar ao superior. Sobre os valores em dinheiro, eram notas trocadas, aproximadamente 380/390 reais em espécie. Daniel e Denise informaram que a casa era alugada e que eram moradores e locatários. Josuel apenas passava alguns dias. Daniel e Denise confirmaram que realizavam a venda. A balança tinha uma substância branca/amarelada, característica de entorpecentes. A porção menor tem um peso aproximado de 3g/5g. Já as 3 porções maiores pesaram, aproximadamente, 900g. O usuário acompanhou-os até a residência e acompanhou na viatura. Evitou colocar o usuário frente aos traficantes, por segurança.

Pedro Luiz Abreude Campos (testemunha comum) prestou depoimento harmônico com a versão apresentada pelo outro policial. Afirmou que abordaram Erivaldo, que tinha um cachimbo para uso de crack. Indagado a respeito, ele confirmou que teria comprado drogas, na rua Santos Dumont, 367. Foram até a residência e, na cozinha, encontraram Denise. Denise franqueou a entrada. Na sala, abordaram Daniel e Josué. No quarto e na cozinha, encontraram os entorpecentes (crack e maconha). Tinha 209 invólucros de maconha e 03 pedaços grandes (900g). Encontraram, ainda, uma balança de precisão e 36 invólucros de crack, dentro de um pote branco. A quantidade encontrada caracteriza o tráfico. O usuário indicou a casa, os residentes tinham passagem por tráfico. Denise, inclusive, era procurada por furto. Denise acompanhou a revista na residência. Daniel assumiu o tráfico e Denise afirmou que o auxiliava a fazer tráfico. Foi apreendida uma balança de precisão, com resquícios de drogas. Foi apreendido um caderno, com folha de contabilidade no tráfico, além de R\$ 389,00. O dinheiro estava em notas de pequeno valor, provavelmente oriundos da traficância. O crack era vendido no valor de R\$ 10,00. Foi a primeira abordagem feita nos réus. O depoente trabalha no Batalhão de Operações Especiais e faz

patrulhamento em vários municípios (96 municípios). Não trabalha em José Bonifácio e não conhece os traficantes de todas as cidades. Erivaldo indicou que a venda foi feita pelo casal. Daniel assumiu o tráfico. O local da residência é no centro de José Bonifácio, com grande movimento de pessoas. Erivaldo indicou que teria um casal que faria a traficância nesse local. Denise foi a primeira a ser identificada na grade da casa e autorizou a entrada da equipe na residência. No caso da ocorrência, o tenente Torres participou ativamente da ocorrência e ele responde como supervisor no período noturno. Josuel, que estava na casa, também é usuário de drogas. Erivaldo indicou que sabia que a residência era local de tráfico de drogas. Pela experiência como policial, a quantidade de drogas é considerada elevada para a cidade. A quantidade de drogas é encontrada em grandes centros. No local, também havia uma moto que seria de leilão. Os pedaços maiores de maconha, se fatiadas, geraria uma quantidade ainda maior de invólucros de porções individuais, gerando uma venda exorbitante.

Erivaldo Pereira dos Santos (testemunha comum) disse que, no dia, estava na rua e foi abordado pela polícia. Os policiais o abordaram e não acharam nenhuma droga. Eles pressionaram e já sabiam o endereço. Foram até a casa da pessoa e acharam crack. Comprou crack da pessoa. Comprou crack por uma ou duas vezes na casa. Quem entregava o crack era sempre Daniel. Na casa, moravam Daniel e a namorada Denise. Denise nunca entregou nada ao depoente. Não sabe se Denise o ajudava a preparar a droga. Ia comprar drogas em um horário que não encontrava ninguém. Só comprava crack. Ficou dentro da viatura, não viu a revista policial. Encontrou Daniel na rua e ele ofereceu drogas. Nunca viu o réu Daniel oferecendo drogas para outras pessoas. Já sabia o local de morada deles. Quando chegaram na casa, já tinha uma viatura invadindo. No dia, quando pegou a droga, recebeu-a apenas de Daniel. Não viu outras pessoas. Quando o depoente chegou, a outra viatura já estava lá dentro. Daniel também é usuário de drogas. Denise também é usuária. Esteve na casa para comprar drogas algumas vezes. Nessas vezes, sempre chamava Daniel no portão. Denise nunca atendeu o depoente. Indicou o endereço para os policiais. Denise entregou ad roga sim, duas ou três vezes. Na maioria das vezes, foi Daniel foi até o portão. Também recebeu drogas de Denise duas ou três vezes. Está sendo intimidado em razão dos fatos por algumas pessoas. Muitos usuários o mandaram "ficar esperto". Não recebeu ameaça vindo direto deles para audiência.

Josuel Araújo Lima (testemunha comum)- desistência da oitiva.

Daniel de Souza (réu) disse que tem 38 anos. Não trabalhava antes da prisão. Tinha saído da penitenciária em novembro, fazia 03/04 meses. Não tinha renda no período. É divorciado. Não tem filhos. Disse que, na casa, tinha 36 porções de crack. Os outros objetos não estavam no local. É usuário de crack. O crack é do depoente. O crack era para uso. Pegou o dinheiro da esposa para comprar crack. Pagou 360 reais de crack para usar. Não apresentaram o restante da droga para o depoente, não chegaram a apresentar a maconha. Não conhecia os policiais e não tinham problema pessoal com ele. Erivaldo é usuário de crack e já usavam juntos. Tinha costuma de usar drogas com ele. Era amigo de Erivaldo. Erivaldo tinha discussão com sua mulher. Sempre ajudaram Erivaldo, ele sempre comia em casa. Ele sempre discutia com sua esposa Denise. Pelo nome, se for quem está pensando quem é, ele sempre comeu em casa. Pelé frequentava a casa do depoente e usava drogas. Não entregou drogas para Pelé naquele dia. Naquele dia, bem antes, usou drogas com Pelé, na hora do almoço. Quando a polícia entrou na casa, Alemão estava no local. Ele se chama Josuel. Estava usando drogas. Quando a polícia chegou, o depoente estava usando drogas com Josuel, dentro do quarto. Também foi encontrado dinheiro no local. A esposa da depoente trabalhava em um restaurante. Ela tinha pegado um acerto. A esposa também vendeu lingerie, doces. O dinheiro ou é do acerto ou da venda. Tinha uma folha de anotações, que era da venda de lingerie e de doces. Comprou a droga às 7/8h da noite. A esposa sabia que era usuária. A esposa não estava em casa, mas pegou o dinheiro com ela. Saiu da prisão em novembro e estava morando com Denise há dois meses. A filha de 11 anos de Denise não mora com ela, mas sim com o pai. A lingerie e os doces eram vendidos para as amigas, conhecidos. Denise trabalhava no La Vitória, mas tinha saído do trabalho. Não sabe o nome do patrão, mas sabe que Denise tinha um dinheiro com o "patrão". Não sabe se o nome é Silvinho. O patrão

não é patrão do tráfico. Denise também pegava doces e roupas para eles. Denise não permitiu o ingresso dos policiais. Não tinha cachorro com os policiais. O depoente usa drogas desde 18 anos. Denise não sabia que o depoente tinha 36 porções na casa. Pelé não tinha problemas com o depoente, mas não sabe dizer quanto a sua esposa. Na comercialização de drogas, há várias porções de variados preços. Tem interesse em fazer tratamento para se livrar do vício. Não tem condições financeiras e não é traficante. Os policiais simplesmente entraram na casa.

Denise de Campos Bicudo (ré) disse que tem 42 anos. Trabalhava em um restaurante em José Bonifácio e tinha pedido a demissão. Fazia eventos em um buffet, por dia, além de uma choperia. Ganhava 1500/1800 reais. É solteira. Tem uma filha de 11 anos. Já tinha respondido a outros processos, quando era usuária. Disse que os policiais entraram em sua casa. O portão estava fechado e a depoente fazia jantar no fogão. Os policiais pediram para desligar o fogão, levaram-na na sala, além de colocar Daniel e o amigo no chão. Eles entraram na sala sem autorização. Os policiais não tinham mandado e disseram que entrariam sim dentro da casa. Não pode acompanhar a revista na casa. Na garagem da casa, estava uma moto Biz da depoente, que fora adquirido de um casal, que disse que era leilão. Os policiais voltaram do quarto com uma porção de drogas. Disse à depoente que não sabia de quem era a droga. Daniel disse que a droga era dele. A droga eram bolinhas embaladas, acredita que era crack. A maconha não foi apresentada, nem a balança de precisão. O crack foi colocado sobre o sofá. Daniel é esposo da depoente, morava com ela há pouco tempo. Não sabia da existência do crack. Tinha 380 reais, que era da venda de lingerie e um pouco de pagamento. Não conhecia os policiais e não tinha problema pessoal com eles. Não conhecia Erivaldo. No local, tinha uma folha de anotações das vendas de lingerie e de doce de pote. As porções encontradas estavam dentro de um saquinho verde. Não reconhece a balança. Depois da abordagem, não teve mais contato com Daniel. Daniel é usuário de crack. Daniel tinha acabado de sair da cadeia e disse que estava indo atrás de serviço. A depoente trabalhava muito e quase não ficava em casa. Vendia lingerie e doces de forma autônoma. A pessoa deixava sacolas com mercadorias e a depoente ganhava por porcentagem. O patrão na fl. 260 é Silvinho, da choperia da fábrica. Silvinho comprou cuecas e doces de pote. Não conhece a pessoa de Erivaldo. Erivaldo está mentindo, já que não tem mais envolvimento com droga há 05 anos. Se Daniel estiver vendendo, ele estava fazendo escondido, porque não aceitava drogas na sua casa. Sabe apenas que Daniel é viciado. Os policiais não entraram na cozinha. Não viu maconha sendo encontrada. Disse aos policiais que não poderiam entrar na sua casa e, mesmo assim, eles entraram. As portas estavam abertas. O portão estava fechado. Os policiais entraram sem permissão e sem perguntar nada. Já foi usuária, mas não usa há 05 anos. Daniel não tinha condições econômicas, estava desempregado. Quem sustentava a casa era a depoente. Daniel, às vezes, fazia bicos. Os PMS não estavam com cachorros. Os policiais levaram o seu cachorro e não sabe onde ele está. Não teve direito à ligação, os policiais invadiram sem autorização. Não tinham drogas na sua casa. Finda a instrução processual, as provas produzidas nos autos são suficientes para fundamentar um decreto condenatório quanto ao delito do artigo 33, da Lei de drogas.

O réu Daniel, perante a Autoridade Policial, permaneceu em silêncio (fls. 07/08). A ré Denise, na fase extrajudicial, disse que: "na data de ontem, no começo da noite, chegou em casa e iniciou o preparo do jantar, algum tempo após, apareceram policiais militares que abordaram a interroganda. Não autorizou a entrada dos policiais militares em sua residência. Realizada busca na interroganda, encontraram apenas seu aparelho de telefone celular. Os demais também foram abordados, porém, não sabe se algo foi encontrado com eles. Acompanhou as buscas dos policiais, que encontraram crack no quarto do casal. Não acompanhou o encontro de drogas no motor da geladeira. A droga encontrada não pertence à interroganda, e não sabe informar a quem pertence. Não tem envolvimento com o tráfico, sendo somente usuária de crack. Com relação ao Josuel, afirma que somente prestaram auxílio, fornecendo banho e comida que solicitou. Tem passagens por tráfico ocorrido em 2005, e furto. Deixou o sistema prisional à cerca de um ano, e não sabe porque está sendo procurada pela justiça. Afirma que não vende e não vendeu, nesta data, drogas para qualquer

pessoa" (fl. 15).

Em juízo, os réus negaram a prática dos delitos.

No entanto, a negativa é inverossímil e está isolada nos autos, não podendo prosperar. As versões apresentadas pelos acusados não convencem.

Tanto Denise, como Daniel informaram que possuíam apenas as porções de crack, que se destinavam ao uso de Daniel. Negaram que as porções de maconha tenham sido localizadas na residência. Ora, tal narrativa não se reveste de credibilidade ou lógica. Não é minimamente crível que o réu tenha adquirido e guardava 36 porções de drogas para uso próprio, sobretudo porque confirmou não possuir qualquer trabalho lícito ou fonte de renda. Quanto à negativa do encontro da maconha, tal fato não demanda maiores discussões. Está plenamente demonstrado que a residência abrigava as porções de maconha descritas na denúncia, seja pela prova testemunhal (depoimentos dos policiais militares), seja pela prova documental (auto de exibição e apreensão e laudos periciais).

Soma-se a isso que, quanto ao delito tráfico, há a palavra firme e coerente dos policiais militares. Em juízo, sob o crivo do contraditório e com o compromisso de dizer a verdade, os agentes públicos declararam, de forma coerente e harmônica, o encontro das drogas, com os réus.

Os policiais confirmaram que, durante busca pessoal no usuário Erivaldo Pereira dos Santos, encontraram um cachimbo para fumar crack. Questionado, Erivaldo informou que comprou uma pedra de crack de um casal, pelo preço de dez reais, na Rua Santos Dumont, 367 - fundos, próximo do local da abordagem, e que já havia consumido a droga.

Na sequência, dirigiram-se ao endereço informado e encontraram DENIZE DE CAMPOS BICUDO, que estava na porta da cozinha e autorizou a entrada na residência. Na sala, estavam o denunciado DANIEL DE SOUZA e o amigo Josuel Araújo de Lima. Em buscas pelo imóvel, encontraram, numa sapateira, no quarto do casal, um potinho branco contendo trinta e seis invólucros de crack. Na penteadeira, encontraram trezentos e oitenta e nove reais e uma folha de caderno contendo anotações da contabilidade do tráfico. Na cozinha, no motor da geladeira, encontraram duzentos e nove porções individuais de maconha, embaladas e prontas para venda, bem como três pedaços grandes de maconha. Na gaveta do armário na cozinha, encontraram uma balança de precisão com resquícios de cocaína e maconha.

Nesse ponto, é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório (RT 530/372).

A crítica costumeiramente expendida em relação ao depoimento de policiais carece de fomento jurídico, diante dos termos peremptórios do artigo 202 do Código de Processo Penal, cujos depoimentos, desde que verossímeis coerentes e não desmentidos pelo restante da prova, podem servir de base à decisão condenatória (RT 445/382). Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"Habeas Corpus. Processual penal. Tráfico de entorpecentes. Condenação devidamente amparada no conjunto probatório dos autos. Testemunho policial. Eficácia probatória. Valoração das provas. Impossibilidade na via eleita. Precedentes do STJ. 1. Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório e aliado a outros elementos de prova a corroborar a condenação. 2. É inviável no presente writ a análise do valor das provas contidas nos autos para a condenação, uma vez que, além de ferir o princípio do livre convencimento do juiz, tal matéria escapa ao âmbito de apreciação do habeas corpus, em face da necessidade do exame minucioso do material cognitivo colhido no processo. 3. Ordem denegada" (HC 30776/RJ; Ministra Laurita Vaz, j. 03/02/2004, DJ

08.03.2004, p. 304).

De maneira semelhante, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

ROUBO – materialidade – auto de exibição, auto de reconhecimento de pessoa e prova oral que comprovam a subtração de bens das vítimas mediante grave ameaça. ROUBO – autoria – confissão dos acusados – validade – depoimento policial corroborando a versão da vítima – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso por parte da autoridade – declaração de vítima imputando aos acusados a conduta delituosa – validade. CONSUMAÇÃO – ocorre com desapossamento – cessada violência ou grave ameaça. PENAS – base no mínimo – manutenção, ausente recurso ministerial – segunda fase – menoridade e confissão – não diminuição – penas que não podem ficar aquém do mínimo legal – terceira fase – concurso de agentes – aumento de 1/3 – reprimendas mantidas. REGIME – fechado – manutenção – gravidade do delito e circunstâncias judiciais desfavoráveis – único regime capaz de adimplir as funções da pena – provimento parcial aos recursos defensivos. (TJSP; Apelação Criminal 1500261-53.2018.8.26.0617; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jacareí - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/02/2022; Data de Registro: 25/02/2022)

Dano qualificado. Réu que danifica encanamentos da cela da cadeia pública de Capão Bonito, em que estava custodiado. Negativa do acusado isolada nos autos. Palavras dos policiais civis coerentes e seguras. Condenação bem decretada. Penas fixadas no mínimo. Réu primário. Regime aberto adequado. Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Apelo improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1500084-82.2019.8.26.0123; Relator (a): Pinheiro Franco; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Capão Bonito - 2ª Vara; Data do Julgamento: 04/03/2022; Data de Registro: 04/03/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de entorpecentes e Associação para o tráfico. Recurso Defensivo e Ministerial. I - Preliminar de cerceamento de Defesa afastada. Resposta a acusação antes do recebimento da denúncia. Rito correto. II - Mérito. Condenação mantida. Provas suficientes da autoria e materialidade delitiva. Confissão de dois réus. Valorização das palavras dos policiais e prova da apreensão das drogas. Destinação mercantil dos entorpecentes deduzida, com segurança, pelas particularidades do caso concreto. Vínculo estável e duradouro comprovado. II - Penas alteradas. Aumento da base justificado. Majoração pela multirreincidência aplicada. Reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas. Pena de multa devida. Regime prisional mantido no fechado. APELOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS E PROVIDO, EM PARTE, O RECURSO MINISTERIAL. (TJSP; Apelação Criminal 0001756-43.2018.8.26.0542; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barueri - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/02/2022; Data de Registro: 18/02/2022)

Ficou claro que não há qualquer indício de parcialidade no depoimento dos policiais, uma vez que nenhum dos acusados indicou a existência de problemas pessoais com os agentes públicos e, portanto, não souberam apresentar motivo apto a afastar a credibilidade dos depoimentos. Ainda, a versão dos policiais é amparada pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos periciais acostados nos autos, os quais comprovam a apreensão da droga mencionada. E não é só. Ouvido com o compromisso de dizer a verdade e sob o crivo do contraditório, a testemunha Erivaldo confirmou que costumava adquirir drogas do casal, já que é usuário de crack. Esclareceu que, na maioria das vezes, Daniel era o responsável por entregar os entorpecentes, embora, em duas oportunidades, também adquiriu entorpecentes diretamente da acusada. Denise afirmou não conhecer Erivaldo, ao passo que Daniel disse que a testemunha era seu amigo. Logo, também não há razões para indicar uma falsa acusação por parte de Erivaldo. Observo que, para a caracterização do tráfico, não se analisa apenas a quantidade

da droga, mas também as circunstâncias da apreensão. Com efeito, a análise do crime de tráfico (artigo 33, caput, Lei 11.343/06) exige a avaliação de todas as circunstâncias do caso concreto. No caso, as circunstâncias da apreensão da droga, bem como o teor da prova oral produzida, demonstram que os acusados guardavam a droga, com plena consciência e agindo de forma dolosa.

Isto porque, em fiscalização, realizada busca na residência, os policiais lograram encontrar 03 tijolos de maconha, pesando 870 gramas no total, 209 porções de maconha, pesando 512 gramas, e 36 porções de crack, pesando 32,30 gramas. A quantidade de droga apreendida é muito expressiva, especialmente em pequenas cidades, como em José Bonifácio.

Cite-se, aqui, lição de FERNANDO DE ALMEIDA PEDROSO, segundo o qual “em sede de tráfico de substância entorpecente, constitui prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. “Prova Penal”, ed., RT, 2004, item 5, pág. 96).

Soma-se a isso que também foram localizados uma balança de precisão com resquícios de cocaína e maconha (laudo pericial); uma folha contendo anotações típicas de tráfico (nomes e numerações) e R\$ 389,00, valores sem origem lícita comprovada, conforme auto de apreensão de fls. 118/119 e fotografia de fl. 120.

A versão da Denise quanto às anotações e origem do dinheiro não merece ser acolhida, já que não está minimamente comprovada. Ora, sua versão poderia ser facilmente demonstrada por testemunhas ou, ainda, por documentos. Entretanto, a acusada não procedeu dessa forma, a demonstrar que não tinha como comprovar a origem lícita do dinheiro ou afastar o caráter de contabilidade do tráfico para as anotações.

Sobre a posse de petrechos como elemento apto a confirmar a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – APREENSÃO DE DROGAS VARIADAS, INDIVIDUALIZADAS EM PORÇÕES E PRONTAS PARA VENDA NO VAREJO (DUAS PORÇÕES DE MACONHA PESANDO 287,5 GRAMAS E 7 PORÇÕES DE CRACK PESANDO 5,95 GRAMAS), ALÉM DE R\$ 340,00 EM DINHEIRO, FRUTO DA VENDA DE ALUCINÓGENOS, BEM COMO PETRECHO LIGADO AO NARCOTRÁFICO (BALANÇA DE PRECISÃO) – MERCANCIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO CORRETA – PENA BEM DOSADA – REGIME ADEQUADO – NÃO PROVIMENTO DO APELO. (TJSP; Apelação Criminal 0006944-85.2018.8.26.0196; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/04/2020; Data de Registro: 29/04/2020)

TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINAR – Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Inocorrência – Rejeição. MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Apreensão de considerável quantidade de entorpecentes (55 porções de cocaína, com peso de 29,8 gramas e 76 porções de maconha, com peso de 183,3 gramas), além de dinheiro e petrechos – Condenação mantida. PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos patamares. Quantidade de entorpecentes apreendidos. Exasperação na fração de 1/6. Proporcionalidade – Inviável o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I e III) – Apelo provido em parte para reduzir as penas. (TJSP; Apelação Criminal 1502446-43.2019.8.26.0548; Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/04/2020; Data de Registro: 13/04/2020)

Deste modo, todos os elementos de prova, analisados conjuntamente, demonstram, de forma inequívoca, que as substâncias entorpecentes pertenciam aos acusados e se destinavam à venda.

A Jurisprudência dos Tribunais é clara no sentido de elencar alguns, dentre os vários elementos de convicção a evidenciar a condição de traficante. Confira-se:

“Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a prisão” (Ap. Crim. 152.279.3, 3ª Câmara, j. 19.06.95 Rel. Des. Bittencourt Rodrigues).

“Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga à terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercância se destina o tóxico encontrado” (TJSP Ap. 187.915-3/2 Rel. CRISTIANO KUNTZ - RT 727/478).

“Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido (TJSP “RT”729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito” (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3, 3.8.94, p.8745).

Vale ressaltar que, para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes, basta a ocorrência de um dos verbos do tipo penal (artigo 33, Lei 11343/06), o que, neste caso, constitui guardar/ter em depósito entorpecentes sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O crime de tráfico ilícito de drogas é de natureza permanente, que se consuma com a simples posse pelo agente, para fim de entrega a terceiro, sendo, portanto, desnecessário que seja flagrado vendendo a droga.

Além do mais, pode coexistir, na mesma pessoa, a figura de traficante e usuário. O fato de, eventualmente, ser usuário de substância entorpecente não obsta ao reconhecimento da figura de traficante. Ao contrário, é natural que ambas as condições, a de usuário e a de traficante coexistam, pois, com a arrecadação obtida com a venda do entorpecente, possibilitar-se-á o emprego na compra, para que o vício possa ser sustentado, como mencionado pelo próprio acusado.

Outrossim, a alegação de usuário ou de “viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (RJTJESP 101/498).

Logo, está comprovada a prática do delito de tráfico pelos acusados.

Por outro lado, melhor sorte não assiste ao delito previsto no artigo 34, da Lei 11.343/06. Isso ocorre porque reputo não se vislumbrar contextos autônomos e coexistentes que vulnerem de modo significativo e distinto o bem jurídico tutelado. O Ministério Público considerou que a apreensão de balança contendo resquícios de entorpecente constitui material notoriamente empregado para preparar e embalar entorpecentes destinados à venda, que exigem pesagem precisa, o que caracterizaria o crime autônomo.

Entretanto, ressalvado e respeitado esse entendimento, uma vez comprovado o tráfico de drogas, a mera posse de balança de precisão, ainda que apreendida com resquícios das drogas nela preparada, caracteriza meio normal para a execução ou exaurimento do delito-fim tencionado pelos agentes e capitulado no artigo 33, da Lei n. 11.343/06. Assim, o delito de tráfico deve absorver a conduta imputada com fundamento no artigo 34, do mesmo diploma legal.

É certo que os tipos penais revelam naturezas distintas. Porém, é necessário reconhecer o caráter subsidiário do artigo 34, da Lei de Drogas, de modo que a posse do objeto utilizado pelos agentes com o objetivo de preparar a droga para que fosse comercializada posteriormente, fique sujeita ao princípio da consunção, restando o crime-meio absorvido pelo crime-fim.

Este é o teor de farta jurisprudência do Tribunal Bandeirante:

APELAÇÃO - Tráfico de drogas - Artigos 33 e 34, da Lei nº 11.343/06 - Pleito de

absolvição - Aplicação do princípio da consunção - Tipo penal subsidiário que resta absorvido pelo crime de tráfico de entorpecentes - Absolvição em relação a esse delito - Materialidade e autoria comprovadas nos autos em relação à conduta prevista no artigo 33, da mesma lei - Condenação mantida - Impossibilidade de aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/06 - Dedicção do réu a atividades criminosas - Descabimento da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos - Regime prisional inicial fechado que se mostra adequado à espécie - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1501089-45.2020.8.26.0628; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Embu das Artes - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021)

Apelação criminal - Tráfico de drogas - Sentença absolutória quanto ao crime do art. 34, da Lei nº 11.343/06, e condenatória pelo art. 33, caput, também da referida Lei. Recurso Ministerial, buscando a condenação do réu também como incurso no art. 34, da Lei de Drogas. Materialidade e autoria comprovadas - Prisão em flagrante delito - Apreensão de mais de 4kg (quatro quilogramas) de maconha - Depoimentos dos policiais civis coesos e harmônicos entre si e em relação àqueles prestados perante a Autoridade Policial - Descrição precisa da prática da traficância de drogas pelo acusado, que foi flagrado enquanto transportava entorpecentes dentro de um veículo - Réu que confessou o crime de tráfico - acusado que franqueou a entrada dos Policiais em sua residência, o que culminou na apreensão de uma balança de precisão - objeto que se mostra como mero instrumento para a consecução do crime tráfico de drogas no caso concreto - ausência de outros petrechos para o tráfico na residência do acusado - princípio da consunção devidamente aplicado na r. sentença e que deve ser mantido em sede de julgamento do recurso de apelação - inviabilidade de condenação pelo delito do art. 34, da Lei nº 11.343/06. Dosimetria da pena - Pena-base bem fixada acima do mínimo legal, diante da elevada quantidade de drogas apreendidas. Inteligência do art. 42 da Lei 11.343/06 - Na fase intermediária, redução ao mínimo legal, diante da confissão espontânea - Na terceira fase, ausentes causas modificativas - redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas incabível, uma vez que ausentes os requisitos legais. Fixação de regime inicial fechado, único compatível com o delito em tela, diante da alta gravidade e reprovabilidade da conduta do réu, em concreto - Impossibilidade de substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque falta amparo legal e em virtude das circunstâncias também não recomendarem a substituição - Tratamento incompatível com os objetivos da Lei de Drogas. Recurso Ministerial desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1501895-65.2020.8.26.0536; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/03/2022; Data de Registro: 21/03/2022)

Portanto, a absolvição é devida, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Da mesma forma, quanto ao delito previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, entendo que o caso é de absolvição. Quanto ao crime de associação, cuja finalidade específica dos agentes é o cometimento dos crimes previstos nos artigos 33 e 34 da Lei nº 11.343/06, o delito reclama uma associação dotada de estabilidade, que não se confunde com o concurso de agentes.

É certo que a testemunha Erivaldo indicou já ter adquirido drogas dos acusados em outras oportunidades. Apesar disso, entendo que, no caso em pauta, não há provas seguras de que os agentes se reuniam, em caráter de estabilidade e permanência, de forma reiterada, para o cometimento do tráfico. A eventual reunião de agentes caracteriza tão só o concurso de agentes, não havendo falar, dessa união, como tipo penal autônomo. Sobre o tema:

Apelação. Tráfico de drogas e associação. Insurgência defensiva. Alegada falta de

provas. Falta de provas verificada apenas em relação ao delito de associação para o tráfico. Acusado abordado juntamente com uma adolescente, em conhecido ponto de venda de drogas. Entorpecentes apreendidos com a adolescente e todo o dinheiro apreendido em poder do apelante. Expediente comum, empregado por traficantes, buscando atribuir integral responsabilidade ao inimputável. Circunstâncias concretas que colocam em descrédito a versão defensiva. Mantida a condenação por tráfico. Art. 35 da Lei 11.343/06. Necessária distinção entre concurso de agentes e associação. Enquanto o primeiro se mostra ocasional e temporário, o segundo exige estabilidade e permanência. Fatos apurados que não demonstram o vínculo associativo duradouro. Existência de vínculo efêmero